

1501884-61.2022.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavio Augusto Reinert de Freitas

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... seu RG acharam uma lista, a qual se referia ao tráfico de drogas. Realizava o tráfico de drogas sozinho há cerca de um mês. O local que realizava o tráfico era um bar, na esquina de sua residência. Estava morando com a sua avó e não com Gilberto. Trabalhava como serralheiro e não trabalhava com Gilberto. Não possuía nenhuma droga no momento da abordagem, apenas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501884-61.2022.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501884-61.2022.8.26.0408

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2107423/2022 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 24414419 -

DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2107423 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILBERTO RAMOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Augusto Reinert

Vistos.

ANDERSON ALVES DA SILVA e GILBERTO RAMOS, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Consta a denúncia que no dia 19 de abril de 2022, às 15h30min, na Rua Jornalista Francisco de Almeida, n.º 83, Parque Minas Gerais, nesta cidade e comarca de Ourinhos, os réus agindo em conjunto, previamente ajustados e em unidade de

propósitos e devidamente associados de maneira estável e permanente há pelo menos um mês, traziam consigo, para fins de tráfico, 05 (cinco) papelotes - com massa de 29,71 gramas - de cocaína, e guardavam 01 (uma) porção grande e 01 (uma) porção menor - com massa de 137,56 gramas - de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram notificados (fl. 174) e os defensores apresentaram defesas preliminares (fls. 177/182 e 196/209).

A decisão de fls. 212/213 recebeu a denúncia no dia 14 de julho de 2022.

Os réus foram regularmente citados (certidão de fl. 238).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma de defesa, seguindo-se pelo interrogatório do réu.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação dos réus nos termos da imputação contida na denúncia.

Em memoriais escritos (fls.267/270), a Defesa do réu Anderson arguiu a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência dos réus e requereu a sua absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas de sua autoria a justificar um decreto condenatório e, subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela atenuante da confissão espontânea e do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, com a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em memoriais escritos (fls.271/276), a Defesa do réu Gilberto, por sua vez, requereu a sua absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas de sua autoria a justificar um decreto condenatório e, subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela desclassificação da conduta do réu do crime previsto no artigo 33, caput, para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06. É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal, que se destina à apuração da responsabilidade do acusado ANDERSON ALVES DA SILVA e GILBERTO RAMOS, pela suposta prática da infração penal prevista nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada.

Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 11/16, auto de exibição e apreensão de fls. 18/19 e fls. 20/21, contabilidade do tráfico de fls. 22/23, laudo de constatação provisória de fls. 25/28, imagens das drogas apreendidas de fls. 29/40, laudo pericial de fls. 162/167, que constatou a existência de cocaína nos apetrechos para o tráfico (colheres, cartões, latas e embalagens do tipo ziplock) empreendidos na residência dos réus, e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 277/282, sem deixar de mencionar a prova oral colhida. A autoria, por sua vez, decorre do depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Na fase extrajudicial, o policial militar Robson Fabricio Quintana de Faria declarou que no batalhão da Polícia Militar há um livro com denúncias anônimas e que no dia 11 de março houve uma denúncia dando conta que os réus estariam

traficando drogas. Na data de hoje, estava patrulhando pelo Parque Minas Gerais quando foi abordado por um morador daquele bairro e este informou que naquele momento estaria ocorrendo à traficância no mesmo local da denúncia realizada no dia 11 de março. Na companhia do Soldado Moraes se dirigiu a residência localizada na Rua Jornalista Francisco de Almeida e lá, visualizou dois indivíduos saindo da residência denunciada. Um dos indivíduos era o réu Anderson, o qual estava com uma corrente e um cadeado em mãos para trancar o portão da residência. Ao perceberem a chegada da viatura policial eles “mudaram o trajeto”, mas foram imediatamente abordados. Na abordagem identificou os indivíduos como sendo Anderson e Gilberto, ora réus, cada um deles estava com uma corrente no pescoço, a qual possuía uma chave. Testou as chaves no cadeado da residência e ambas abriram o cadeado. Naquela residência reside o réu Gilberto, já o réu Anderson reside há duas casas “para baixo”. A casa possui dois cômodos, com dois colchões, onde foi encontrada roupas do réu Anderson. Na entrevista do réu Gilberto, ele confirmou que o réu Anderson estaria morando ali. Na abordagem pessoal do réu Gilberto, foi encontrada, no bolso de sua bermuda, três porções de cocaína conhecidas como “Aricanduva”, já embaladas e prontas para a venda. Já com o réu Anderson foi encontrada duas porções de cocaína, “Aricanduva”, idênticas as porções encontradas com Gilberto. Os réus foram separados para serem interrogados. Assim, Gilberto informou que estava realizando a venda de drogas para pagar o seu aluguel e que dentro de sua residência havia mais drogas. Gravou um vídeo com a autorização de Gilberto para franquear a entrada dos policiais em sua residência. Além disso, Gilberto indicou o local em que as drogas estavam escondidas e mostrou uma blusa de cor preta, dentro de um guarda-roupa, que possuía uma porção de cocaína ainda sem ser “batizada”. Essa droga estava em um invólucro e possuía uma anotação colada indicando o número 25. Ainda, Gilberto falou que teria pagado o valor de R\$ 600,00 (seiscentos) reais por essa droga, sendo que ele teria dado a metade do valor e a outra metade foi paga por Anderson. Sobre o guarda-roupa, foi localizada uma “latinha” com apetrechos para embalar a droga, também foi encontrado um pote branco com cocaína já “batizada”. Também foi encontrada uma sacola com uma substância branca, a qual os réus não souberam informar do que se tratava, mas que utilizavam para misturar com a cocaína. Foi localizada outra porção de cocaína, “Aricanduva”, dentro da residência e idêntica às porções encontradas com os réus. A todo o momento, Gilberto confirmou que as drogas encontradas eram de compras anteriores e que junto com Anderson estava realizando a traficância, bem como dividiam os gastos com as compras de drogas e os lucros após as vendas. Foi dada voz de prisão aos réus. Indagou Anderson, após Gilberto ter confessado a traficância, o qual negou estar traficando drogas e disse que teria pegado a chave da residência de Gilberto apenas naquele momento, mas não soube explicar porque estava com a chave. No entanto, na delegacia, foi solicitado o RG de Anderson e se descobriu que no meio deste documento havia um papel com os valores a serem cobrados pela venda de drogas. Novamente indagou Anderson e lhe mostrou o papel encontrado, quando Anderson confessou a traficância e disse que aquele papel era a cobrança de vendas anteriores. No quarto de Gilberto foram encontrados celulares e o valor de R\$ 162,00 (cento e sessenta e dois) reais dentro de uma carteira. O dinheiro é proveniente do tráfico de drogas, conforme confirmou Gilberto. O réu Gilberto já é conhecido nos meios policiais e já foi preso por tráfico de drogas, por sua vez o réu Anderson há duas semanas correu de uma abordagem policial no mesmo local que foi encontrado. (fl. 02 - mídia audiovisual).

Em Juízo, o policial militar Robson declarou que estava em patrulhamento pelo bairro Parque Minas Gerais já com vistas a residência dos réus, uma vez que moradores daquela região já tinham realizado denúncias de que os réus estavam praticando o tráfico de drogas. Na data dos fatos, a viatura da polícia militar foi novamente parada por um morador daquela região e este informou que um dos réus havia saído de sua casa há alguns minutos e que o “tráfico estava forte naquele horário”. Imediatamente, deslocou-se para a rua da casa dos denunciados. Visualizou os réus saindo da residência, quando eles trancaram o portão com um cadeado e seguiram em direção oposta a da viatura. Abordou os réus e em revista pessoal, com Gilberto foi encontrado dentro de sua bermuda três porções de cocaína e com

Anderson duas porções de cocaína, idênticas às porções de Gilberto. As porções de cocaína estavam embaladas em um saco plástico, "zip lock". Além disso, com Anderson foi encontrado um RG e dentro dele um papel com a contabilidade do tráfico de drogas, havia anotações de débitos a receber de usuários de drogas. A casa que estavam defronte é de Gilberto, já Anderson seria seu vizinho. No entanto, Anderson também dorme na residência de Gilberto, bem como foram encontradas roupas de Anderson dentro da casa. Cada um dos réus possuía uma chave, pendurada no pescoço, que abria o cadeado do portão, ou seja, ambos tinham acesso à residência independente do horário. Assim, Gilberto foi separado de Anderson e foi indagado quanto à traficância, quando assumiu que estaria traficando para conseguir pagar o seu aluguel e que teria mais drogas dentro de seu quarto na sua residência. Foi realizado um vídeo em que Gilberto autorizou a entrada dos policiais militares na residência. No quarto de Gilberto, dentro de uma blusa, de cor preta, foi localizada uma porção de cocaína em estado bruto, a qual Gilberto teria pagado juntamente com Anderson a quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais). Gilberto também informou que não foi a primeira vez que teria comprado junto com Anderson uma quantia maior de drogas para fracionarem e fazerem a venda posteriormente, como também dividem os lucros das vendas de drogas. Em cima do guarda-roupa havia uma lata de alumínio contendo um "saquinho" de cor branca com uma mistura, segundo Gilberto aquela mistura seria "cocaína batizada", ou seja, os réus compravam a droga e depois a misturavam com outra substância para fazerem mais porções das drogas. Foram localizados três aparelhos celulares e a quantia de R\$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais). Diante da autoria e da materialidade foi dada voz de prisão aos réus e conduzidos à delegacia de polícia. Os réus estavam traficando há cerca de um mês, pois a polícia militar já estava monitorando os réus. Esclareceu que no momento que visualizou os réus, eles estavam saindo da residência de Gilberto e após serem abordados pelos policiais militares retornaram para a residência para que efetuassem as buscas. Junto dos réus tinham usuários, mas estes saíram do local assim que perceberam a chegada da viatura policial. As drogas dentro da residência foram indicadas por Gilberto. (fl. 261 – mídia audiovisual). Na fase extrajudicial, o policial militar Vinicius Corrêa de Moraes declarou que estava em patrulhamento na companhia de seu colega de farda o Sargento Faria, quando foram abordados por um popular que realizou uma denúncia anônima dando conta que na residência dos réus estaria ocorrendo à traficância. Deslocou-se ao local da denúncia e avistou dois indivíduos saindo de uma residência, os quais avistaram a viatura da polícia militar e trancaram o portão da referida residência e saíram "meio confusos, demonstrando nervosismo". Durante a abordagem pessoal, os indivíduos foram qualificados como Anderson e Gilberto. Com Gilberto foram localizadas três porções de cocaína e com Anderson duas porções, também de cocaína. Solicitou o apoio policial. Entrevistou os réus separadamente, quando Gilberto confessou o tráfico de drogas e que dentro de sua residência havia mais drogas, as quais comprava em conjunto com Anderson. Com o apoio policial, realizou a busca pela residência de Gilberto e encontrou mais drogas e apetrechos para misturar as drogas. Havia uma "latinha" de alumínio com resquícios de drogas e também colheres. Ademais, foi localizada uma embalagem transparente com uma substância que era usada para misturar com a cocaína. Havia uma pedra maior de cocaína dentro de uma blusa de cor preta. Dentro de uma lata, foi encontrada uma porção de cocaína, "Aricanduva", igual às porções encontradas junto com os réus. Junto com Gilberto foi encontrada a quantia de R\$ 162,00 (cento e sessenta e dois) reais, já os celulares encontrados estavam dentro de uma lata. Cada um dos réus estava com uma corrente no pescoço e com uma chave pendurada, essas chaves eram da residência de Gilberto. Inicialmente, Anderson informou não residir naquela casa, porém, foram encontradas roupas de Anderson em um dos cômodos da casa. Já Gilberto, confessou que Anderson residia com ele. Quando solicitou o RG de Anderson, dentro dele havia um papel contendo "contabilidade do tráfico", ou seja, o nome de pessoas, valores e especificações sobre o tipo de droga vendida. Foi dada voz de prisão aos réus. (fl. 03 – mídia audiovisual).

Em Juízo, o policial militar Vinicius declarou que na data dos fatos estava em patrulhamento na companhia do seu colega da farda o Sargento Faria. Havia denúncias

em desfavor dos réus, as quais informavam que eles estariam realizando o tráfico de drogas. Avistou os réus defronte a um portão, sendo que eles ao perceberem a presença da viatura policial, trancaram o portão e “ficaram meio perdidos quanto ao sentido que iriam tomar”. Os réus foram abordados e em revista pessoal junto com Gilberto foram encontradas três porções de cocaína e com Anderson duas porções de da mesma droga. As porções estavam embaladas em “zip lock” e eram idênticas. O réu Gilberto foi indagado e confessou estar traficando e que precisava pagar o seu aluguel. Além disso, Gilberto informou que venderia cada porção pelo valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), foi questionado se havia mais drogas e ele confirmou que dentro de sua residência havia drogas, assim, franqueou a entrada dos policiais e indicou o local que a droga estava. Dentro de uma blusa, de cor preta, foram localizadas mais substâncias entorpecentes e em cima de um guarda-roupa um pote de alumínio e dentro desse um pote branco com cocaína já misturada com outra substância. Gilberto confessou que comprava a droga junto com Anderson e que teriam comprado a droga encontrada por R\$ 600,00 (seiscentos reais), sendo que cada um deles pagou R\$ 300,00 (trezentos reais), posteriormente misturariam aquela droga para a venda. No local, também foram apreendidos três celulares e o valor de R\$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais). Salientou que ambos possuíam a chave do portão daquela residência. Com Anderson, foi localizada, dentro de seu RG, uma folha contendo anotações referentes ao tráfico de drogas. Foi dada voz de prisão aos réus. As denúncias de que os réus estavam traficando chegaram a cerca de um mês, as quais foram lançadas em um livro do Batalhão. No momento da abordagem, o réu Anderson não falou nada sobre os fatos. No local da abordagem não havia outras pessoas. (fl. 261 – mídia audiovisual).

Em Juízo, a informante Jessica Silva e Souza declarou que considera o réu Gilberto como sendo um pai para ela e o réu Anderson como o seu melhor amigo. Na data dos fatos, foi até a residência de Gilberto por volta das 12h30min e viu quando os policiais militares adentraram a residência. Já Anderson estava do lado externo da residência, mas Gilberto estava dentro da residência deitado. Naquela casa residem outras pessoas além de Gilberto, as quais estavam do lado externo da residência na data dos fatos. Quanto a Anderson tem conhecimento que ele estava residindo com sua avó, em outro imóvel. Não sabe dizer se com Anderson havia drogas, mas que anteriormente quando teve contato com os réus eles não estavam com nenhuma droga. Não havia drogas com Gilberto e com Anderson. (fl. 261 – mídia audiovisual).

Interrogado perante autoridade policial, o réu Anderson Alves da Silva manifestou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 04 – mídia audiovisual). Interrogado em Juízo, o réu Anderson negou os fatos narrados na denúncia. Disse que um dia antes dos fatos posou na residência de Jessica e no outro dia voltou à residência de Gilberto na companhia dela. Estava saindo da residência de Gilberto para ir à casa de sua avó, quando foi abrir o portão os policiais militares chegaram e o “enquadraram”. Os policiais militares adentraram a residência de Gilberto. Não possuía nenhuma droga consigo. Foi levado para a delegacia e dentro do seu RG acharam uma lista, a qual se referia ao tráfico de drogas. Realizava o tráfico de drogas sozinho há cerca de um mês. O local que realizava o tráfico era um bar, na esquina de sua residência. Estava morando com a sua avó e não com Gilberto. Trabalhava como serralheiro e não trabalhava com Gilberto. Não possuía nenhuma droga no momento da abordagem, apenas possuía uma lista relacionada ao tráfico de drogas. Não admitiu para os policiais que realizava o tráfico de drogas. Não viu os policiais encontrando nenhuma droga. Possui vinte e dois anos de idade. Não foi preso e nem processado anteriormente. Não sabe dizer se Gilberto é usuário de drogas, por outro lado informou ser usuário de cocaína e “maconha”. Não tinha a chave da residência de Gilberto, na data dos fatos apenas pegou uma chave em cima da cama de Gilberto para abrir o portão. A chave estava com ele no momento da abordagem, mas não era sua. Esclareceu que a residência de sua avó fica na mesma rua que a residência de Gilberto, mas que sempre morou com sua avó. Não houve nenhum vídeo realizado pela polícia. (fl. 261 – mídia audiovisual).

Interrogado perante autoridade policial, o réu Gilberto Ramos manifestou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 05 – mídia audiovisual). Interrogado em Juízo, o réu Gilberto negou os fatos narrados na denúncia. Disse que

na data dos fatos foi trabalhar e chegou a sua residência por volta das 12h00min, quando foi se deitar porque estava com dor de cabeça. Posteriormente, Jessica chegou a sua residência. Quando os policiais militares chegaram e já adentraram a sua residência. Já Anderson estava no portão da residência, mas não sabe dizer se ele iria sair ou adentrar sua residência. O portão estava aberto. Os policiais militares chegaram e colocaram uma arma em sua cabeça. Possuía 05 g de cocaína que eram para o seu consumo próprio, porque é usuário de drogas. Ninguém sabia que ele possuía essa droga. Um dos policiais militares o levou para fora da residência e fez uma filmagem com ele, falando para ele dizer que autorizava a entrada dos policiais. O policial disse "para eu não esculachar já me fala onde tá", se referindo a drogas. O réu mostrou onde estava as 05 g de cocaína. O restante das drogas que apareceram não sabe dizer de quem eram, mas afirma que possuía apenas 05 g de cocaína. Trabalhava como pedreiro e Anderson era o seu ajudante, por isso Anderson possuía a chave da sua residência e também estava praticamente morando ali. Apenas o policial militar Faria entrou na sua residência. A prova que possui, são os "caras" que estavam no bar da esquina e visualizaram o ocorrido. As 05 g de cocaína de sua propriedade estavam em "um carço só". Não possuía três porções de cocaína. Já foi processado anteriormente por tráfico, há quinze anos, mas foi absolvido. Há cerca de um mês estava morando junto com Anderson. A avó de Anderson morava próxima a essa residência, era raro quando ele ia para a casa da avó dele porque ele fiava mais na sua residência. Quando foi abordado dentro de sua residência pelo policial militar e saiu com ele da residência, avistou algumas pessoas na esquina e também viu os policiais abordarem um indivíduo que estava dentro de um veículo, modelo Gol. O rapaz do Gol foi liberado. Trabalha de segunda a sábado. (fl. 261 – mídia audiovisual).

Estas foram, em resumo, as provas produzidas em cenário judicial, observadas as regras pertinentes ao devido processo legal, em especial do contraditório e da ampla defesa, e que evidenciam a responsabilidade penal dos acusados pelo fato descrito com a denúncia.

A negativa dos acusados está isolada nos autos. A traficância está bem evidenciada, cristalina.

Como se vê, os relatos prestados, tanto em Juízo quanto na fase policial, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si, inexistindo quaisquer elementos que permitissem a ilação de que as testemunhas estariam animadas do propósito de incriminar indevidamente os acusados.

Os policiais militares narraram de forma harmoniosa na fase policial e em Juízo que existiam informações do tráfico de drogas praticados pelos réus e que no dia dos fatos a viatura da polícia militar foi novamente parada por um morador que informou que o tráfico estava ocorrendo naquele momento na residência dos réus. Eles se deslocaram até o local, onde avistaram os réus saindo. Os réus foram abordados e com Gilberto foi encontrada três porções de cocaína, em embalagem do tipo "aricanduva", e com Anderson duas porções da mesma droga, em embalagem idêntica. O réu Gilberto franqueou a entrada dos policiais na residência, onde foi localizada uma porção maior de cocaína com massa líquida de 25,37 g, além de apetrechos para a mistura e embalagens das drogas (colheres, cartões, embalagens do tipo ziplock e lata, todos com resquícios de cocaína, conforme apontou o laudo pericial de fls. 162/167). Ainda com o réu Anderson, junto com seu documento de identidade, foi localizado contabilidade do tráfico (fl. fls. 22/23), com nomes, valores e especificações sobre o tipo de droga vendida. Os policiais ainda narraram que os dois réus possuíam chaves da residência.

Com efeito, as drogas apreendidas, que os réus traziam consigo, destinavam-se à venda, o que se extrai das circunstâncias do caso concreto, vale dizer, pela quantidade, natureza e forma que acondicionada a droga, sendo apreendido com os réus 29,71 gramas de cocaína, na forma de uma porção maior, com 25,37 g e seis porções menores, embaladas e prontas para a venda, com massa de 4,34, além dos apetrechos utilizados no tráfico para a mistura e embalagens das drogas (colheres, cartões, embalagens do tipo ziplock e lata, todos com resquícios de cocaína, conforme apontou o laudo pericial de fls. 162/167), conforme se extrai do auto de exibição e apreensão de fls. 18/19 e 20/21, laudos de constatação provisória de

fls. 25/28, conjugado com laudo definitivo de entorpecentes de fls. 277/282; bem como pelos relatos dos policiais militares, que narraram que havia informação de que os réus praticavam o tráfico de drogas.

Vale recordar, que a venda propriamente dita da droga não é elemento indispensável para a configuração da traficância, tendo em vista consistir o crime de tráfico de em tipo penal misto alternativo, bastando, para a configuração do aludido delito, a prática de qualquer das 18 ações tipificadas (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), dispensada a prova do ato da mercancia em si, perfilhando desse mesmo entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DROGAS. EXPORTAR OU REMETER DROGA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 528. (...) O crime de tráfico de drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos." (STJ, CC 146.393/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 01.07.2016)

"TÓXICO Crime de tráfico Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito Depoimentos de agentes policiais. Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas Análise que se faz em cada caso concreto Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório Policial que se diz usuário Flagrante legal Tipo penal misto alternativo que dispensa a prova da conduta da venda para a prisão e acusação. Condenação mantida Pena correta e adequada ao caso Regime fechado mantido. Recurso improvido." (TJSP, Relator (a): Newton Neves; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2015; Data de registro: 01.04.2015).

Anoto que o valor do depoimento testemunhal dos servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Nesse sentido:

"A prova policial só deve desprezada, afastada, como elemento válido e aceitável de convicção, quando totalmente ausente prova judicial confirmatória ou quando desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes colhidos em juízo através de regular instrução. Havendo, porém, prova produzida no contraditório, ainda que menos consistente, pode e deve aquela ser considerada e chamada para em conjunto com esta, compor quadro probante suficientemente nítido e preciso (RJTERGS 150/143-3)" (Julio Frabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., p. 89, Atlas, 2000).

É pacífico que o depoimento do policial tem o mesmo valor do depoimento de qualquer outra testemunha, já que prestado sob as mesmas condições.

A propósito:

"O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido" (STJ - RESP 200500786783 - (751760 MG) - 5ª T. - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 14.11.2005 - p. 00400).

Inexistindo qualquer indício de que tenham qualquer interesse em incriminar falsamente os réus, seu depoimento merece crédito assim como o de qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS – O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal – O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73518 – Relator: Min. Celso de Mello – 1ª Turma – J. 26/03/1996).

No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que os policiais militares pretendessem prejudicar os réus, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional.

Os réus apresentaram versões mendazes, contraditórias, divorciadas do restante do conjunto probatório coligido nos autos.

Em Juízo, os réus negaram o crime de tráfico de drogas. O réu Anderson disse que estava morando com a sua avó e não com Gilberto. Disse ainda que trabalhava como serralheiro e não trabalhava com Gilberto. Por sua vez, o réu Gilberto disse que Anderson estava morando com ele há aproximadamente 1 mês e que trabalhava como pedreiro e Anderson era o seu ajudante. Gilberto ainda disse que Anderson tinha a chave da residência e que possuía apenas 05 (cinco) gramas de cocaína, da qual se destinava apenas ao seu uso próprio, bem como não soube explicar a origem das outras drogas apreendidas. Anderson confirmou realizar o tráfico de drogas, no entanto negou possuir ou ser o proprietário de qualquer das drogas apreendidas, apenas confirmou que o papel encontrado dentro de seu documento de identificação se referia à contabilidade do tráfico de drogas.

A alegação de que os policiais teriam forjado a apreensão da cocaína não encontra qualquer amparo na prova dos autos.

Também a alegação das Defesas de ilegalidade na abordagem e ingresso dos policiais na residência não merece acolhida. Primeiro porque havia informações do tráfico praticado pelos réus na residência, inclusive de que o tráfico estaria ocorrendo naquele momento e ao patrulharem os policiais visualizaram os réus em frente à residência, sendo que abordados foram apreendidos com o réu Gilberto três papérolas do tipo “Aricanduva” contendo cocaína e com Anderson dois papérolas do mesmo tipo, também com cocaína. Na sequência, conforme registrado em vídeo (fl.17), o réu Gilberto autorizou a entrada na residência, onde foi localizado porção com 25,37 gramas de cocaína e apetrechos para o tráfico reiterado de drogas (colheres, cartões, embalagens do tipo ziplock e lata, todos com resquícios de cocaína, conforme apontou o laudo pericial de fls. 162/167).

Portanto, não houve qualquer ilegalidade na abordagem, precedida de fundada suspeita de ilicitude e no ingresso na residência, precedida de autorização dos moradores, que sequer era exigida no caso, já que havia justa causa para que os agentes públicos entrassem no domicílio sem mandado de busca e apreensão.

Em caso análogo, o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente



caso, em que, antes do ingresso dos policiais, o acusado lançou para fora da janela da casa um pote de "margarina" contendo 11 (onze) buchas de entorpecente conhecido como "maconha". Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão (tráfico) e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1928936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)"

Quanto ao depoimento da informante arrolada pela defesa, ao contrário do que ocorre com os depoimentos dos policiais, nada de esclarecedor trouxe aos autos, eis que próxima dos réus (narrou em Juízo que é a melhor amiga do réu Anderson e tem o réu Gilberto como um pai), outra não poderia ser a conduta dela senão tentar, de todas as formas, inocentá-los de tão grave acusação.

Nesse sentido, o relato da informante, ao dizer que Anderson morava com sua avó, foi contraditório em relação ao relato do próprio réu Gilberto, que narrou em Juízo que Anderson trabalhava e morava com ele há um mês.

Assim, a versão dos acusados de que os policiais teriam forjado sua prisão e conduta delituosa é mendaz, evasiva e inverossímil, além de não ter sido demonstrada pelas Defesas por qualquer meio de prova, que, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 156 do CPP.

Sob tais fundamentos, entre a versão dos policiais militares e a versão dos réus, privilegia-se a dos primeiros. Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS ROBUSTAS CONTRA O ACUSADO. PLEITO DE FLAGRANTE FORJADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ALEGAÇÃO. ARGUMENTO DE CONDENAÇÃO BASEADA APENAS NO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR. VALIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. PRESENÇA NOS AUTOS DE OUTROS MEIOS DE PROVA.

DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A condenação do acusado está satisfatoriamente fundamentada nas provas juntadas aos autos, consubstanciadas no Auto de Prisão em Flagrante Delito, no Auto de Apresentação e Apreensão, no Laudo Pericial Toxicológico e no depoimento do policial responsável pela prisão do apelante. 2. Não há nos autos qualquer prova de que o flagrante foi forjado pelos policiais, nem menção do motivo ou interesse que os policiais tivessem para produzir provas contra um inocente. Dessa forma, o argumento não merece prosperar. 3. O testemunho de policiais tem o mesmo valor probatório do depoimento de outras testemunhas, haja vista que submetido às mesmas regras referentes ao juramento e à pena de falso testemunho, além de também ser colhido sob o crivo do contraditório. Assim, como qualquer outro meio de prova, o depoimento de policiais é, portanto, idôneo para fundamentar a condenação. Precedentes do STF e STJ." (TJSP - Processo: APL 174120078171360PE000001741.2007.8.17.1360. Relator(a): Marco Antônio Cabral Maggi. Julgamento: 23/09/2011. Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal.).

Quanto às denúncias que recaem sobre os réus, no sentido de que estariam praticando o tráfico de entorpecentes, é certo que isoladamente denúncias anônimas não possuem o condão de condenar alguém, mas aliadas a outros elementos probatórios constituem indícios concretos da prática delitiva, como é o caso dos autos, no qual foram apreendidos 29,71 gramas de cocaína, na forma de uma porção maior, com 25,37 g e seis porções menores, embaladas e prontas para a venda, com massa de 4,34, além dos apetrechos utilizados no tráfico para a mistura e embalagens das drogas (colheres, cartões, embalagens do tipo ziplock e lata, todos com resquícios de cocaína, conforme apontou o laudo pericial de fls. 162/167).

Como se observa, ainda que as denúncias anônimas sejam provas indiciárias, quando corroboradas por outras provas dos autos é elemento valioso na análise da adequação típica do tráfico de drogas. Sobre o assunto:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO RECURSAL PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO TRÁFICO DE DROGAS. AS DENÚNCIAS ANÔNIMAS INFORMANDO A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA PELO APELANTE, OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E A POSSE DO RÉU DE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DEMONSTRAM SUA RESPONSABILIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DO CP. QUANTIDADE DOS TÓXICOS APREENDIDOS E PROVA NA HABITUALIDADE

NA VENDA E PLANTIO, NÃO AUTORIZAM SUA APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO" (TJPR - 4ª C. Criminal - AC 0662493-3 - Siqueira Campos - Rel.: Des. Miguel Pessoa - Unânime - J. 01.07.2010) (destaquei).

"Tráfico de entorpecentes - Recurso do Ministério Público Pedido de Condenação do corréu Thiago. Acolhido Autoria e materialidade comprovadas para ambos os réus Robusto conjunto probatório - Seguros e insuspeitos relatos dos policiais militares que confirmaram: a denúncia anônima dando conta da prática do tráfico de drogas praticado por dois indivíduos, passando, inclusive, as características deles; bem como a confissão informal dos dois acusados - Réu que foi visto dispensando quantia em dinheiro em notas amassadas - Atitude comum em coautoria na venda espúria, onde um agente é responsável pelas drogas e o outro pelo dinheiro. Pedido da acusação para aumento da pena base - Possibilidade - Quantidade e diversidade de drogas que justificam o acréscimo nesta etapa. Pedido da acusação para afastar a confissão do corréu Vanderson - Possibilidade - Confissão parcial feita com o intuito de excluir a culpabilidade de seu comparsa, e não com o escopo de auxiliar na resolução da ação criminal - Impossibilidade de concessão do benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas - Réus reincidentes - Regime fechado é medida necessária - Dado provimento ao recurso ministerial." (Apelação Criminal nº 1501052-47.2018.8.26.0544; 7ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Freitas Filho, julgamento em 09.10.2019) (destaquei).

Assim, as denúncias anônimas são importantes fontes de informações para a polícia e, quando são confirmadas com elementos concretos nos autos, merecem guarida para sustentar a acusação de tráfico de entorpecentes, pois não se pode esperar que a pessoa delatora de tão grave delito assuma sem temor sua identidade, ante a usual represália emanada dos inúmeros traficantes de drogas que mutuamente se ajudam. Sobre a destinação da droga, é de se destacar que foram apreendidas com os réus 29,71 gramas de cocaína, na forma de uma porção maior, com 25,37 g e seis porções menores, embaladas e prontas para a venda, com massa de 4,34, o que conduz à segura conclusão de que a droga se destinava ao comércio ilícito, e não ao uso próprio, pois é cediço que, em casos de tráfico, a substância entorpecente, no mais das vezes, é repartida em porções individuais para facilitar o comércio a terceiros. Nesse sentido:

"Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - rel. ENÉAS MACHADO COTTA, RDTJRJ 23/288).

"Identificando o fornecedor das substâncias tóxicas, em poder de quem foi apreendida expressiva quantidade de cocaína, parte já dividida em dezenas de papелotes, prontos para entrega a consumo, impõe-se a condenação por tráfico, sem que se possa, todavia, reconhecer associação com compradores." (TJRJ - rel. PAULO GOMES DA SILVA FILHO, RDTJRJ 20/313).

Nesse interim, a literatura jurídica revelou que usualmente cada porção de maconha equivale a 0,6 grama (STJRHC nº 37.033/MG - Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz - j. 22.10.2013); cada porção de cocaína equivale a cerca de 0,25 grama (STF HC nº 111.247/MG 2ª Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski - j. 27.03.2012), cada porção de crack equivale a cerca de 0,1 grama (STFHC nº 114.390/RS 1ª Turma Relator Ministro Luiz Fux j. 20.08.2013).

Com base nestes dados, conclui-se que a quantidade de cocaína apreendida (29,71g) seria suficiente para produzir aproximadamente 118,84 porções individualizadas da droga.

Ainda, realce-se "que, consoante a literatura médica e a jurisprudência, a dose letal aos usuários de cocaína corresponde a 0,02g do tóxico; portanto, a quantidade da substância apreendida (7,97g) representa, pelo menos, 398 porções "insuportáveis", ensejando quadro de overdose (Delton Croce e Delton Croce Júnior, "Manual de Medicina Legal", 5ª edição, Editora Saraiva, 2.004, nº. 14.2.11.3, pg. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz, "Medicina Legal e Antropologia Forense", 1ª edição, 1.988, nº. 42, pg. 539; STJ, HC 235.257/DF, DJe 26-3-2013; TJESP, Apelação Criminal nº. 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO), detalhe apto a reforçar o vil comércio" (TJSP - Apelação Criminal nº 0004647-

51.2018.8.26.0408. 2ª Câmara de Direito Criminal. Relator Desembargador COSTABILE E SOLIMENE. Julgamento em 05.08.2019).

Portanto, o fato do laudo definitivo de entorpecentes de fls. 277/282 ter constatado, quanto as porções com massa líquida de 40,72g e 96,84g, referente ao item D e F do laudo, que

"não foi possível identificar presença de substâncias elencadas nas listas E e F da Portaria SVS/MS 344/98 e suas atualizações, ou na Portaria MJ 240/2019, em sua lista III, conforme a(s) técnica(s) utilizadas", embora afaste a parcela da acusação quanto ao referido material, não implica na absolvição ou desclassificação das condutas dos acusados, já que a quantidade remanescente de 29,71g de cocaína, a forma como acondicionada (porção maior e porções já fracionadas, prontas para a venda), aliadas as demais circunstâncias do delito (informações do tráfico praticado pelos réus, apreensão de apetrechos utilizados no tráfico reiterado, todos com resquícios de cocaína, e contabilidade do delito), não deixam dúvidas quanto a traficância.

Ainda, pontuo que se os réus são realmente usuários de drogas, tal circunstância não exclui sua condição de traficante. Ao contrário, reforça-a, pois é comum que o usuário venda drogas para manter seu vício. Aliás, infelizmente esse não é um caminho incomum, ou seja, a prática cotidiana comprova que no mais das vezes o usuário segue o caminho do vício até não poder mantê-lo às suas próprias expensas, e então passa a vender drogas para mantê-lo.

Assim já decidi o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TÓXICOS Tráfico Alegação de ser o acusado usuário de entorpecentes. Irrelevância. Hipótese em que uma conduta não exclui a outra, sendo comum o tráfico entre dependentes ou usuários justamente para viabilizar o sustento do consumo Recurso improvido." (TJSP. Apelação Criminal n. 1.167.864.3/4 Ibitinga 5ª Câmara Criminal, Relator: Juvenal Duarte 15.05.08 M.V. Voto n. 2.478).

Essa a hipótese do caso concreto, em que o fato de os réus serem usuários não os desqualificam como traficantes.

Portanto, em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável a absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta dos réus para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Por outro lado, quanto ao crime de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, embora existam indícios, não há provas estremes de dúvida de que se tenha verificado.

O vínculo associativo é a figura central do tipo penal do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006, e deve ficar comprovado de forma cabal, o que enseja a conclusão de que o mero concurso não basta à tipificação dessa conduta. Ou seja, para a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas, é imprescindível que os agentes pratiquem a conduta em liame subjetivo com a finalidade permanente de tráfico de drogas, de maneira estável e rotineira, o que não se verificou no caso concreto.

Ou seja, embora seja possível que os réus tenham se associado, não se pode afirmar de forma estreme de dúvida que o tenham, já que a prova produzida não autoriza a concluir nada além da simples coautoria e impede a condenação dos réus pelo crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelos réus ANDERSON ALVES DA SILVA e GILBERTO RAMOS, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação de suas penas.

Quanto ao réu Anderson Alves da Silva.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em análise às diretrizes previstas nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, verifico que o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, já que traficava cocaína, droga conhecida por sua natureza altamente viciante, destrutiva e nociva à saúde humana. Assim, "Há que se reconhecer a maior nocividade da cocaína em relação a outras substâncias proscritas, levando-se em conta os efeitos deletérios causados à saúde dos usuários, a dependência psicológica e física, por vezes imediata, por eles provocada, bem como as consequências sociais nefastas acarretadas pelo consumo e

tráfico de tais entorpecentes" (STJ, HC 187330/MG, Relator Ministro GILSON DIPP, julgamento em 03.05.2011).

Portanto, essa circunstância (natureza) autoriza a exasperação da pena em face da maior reprovabilidade da conduta, na esteira do art. 42 da Lei de Drogas, que estabelece a quantidade e natureza da droga como circunstância preponderante na fixação da pena base.

Nesse sentido:

1. A natureza da droga apreendida - cocaína, dotada de alto poder viciante - constitui fundamento idôneo a ensejar a exasperação da pena-base, à luz do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (STJ, HC 338379/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 06.12.2016)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA NOCIVA DAS DROGAS APREENDIDAS (CRACK E COCAÍNA). ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes de tráfico de drogas, o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal - CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) justifica a majoração da pena-base, em relação à Debora, bem ainda a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em seu patamar mínimo, para o réu Geraldo. Precedentes. 3. Ag regimental desprovido." (STJ, AgRg no HC 476995 / SC, 5ª Turma, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgamento em 03.05.2019.)

"O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos" (STJ, 5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12).

"No crime de tráfico de drogas, a quantidade e a variedade do entorpecente devem ser consideradas na fixação da pena base, amparada no art. 59 do Código penal, uma vez que, atendendo à finalidade da lei 6.368/76 (atual Lei n. 11.343/06), que visa coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, esses fundamentos apresentam-se válidos para individualizar a pena, dado o maior grau de censurabilidade da conduta. Precedentes" (STJ, 5ª T., rel. Arnaldo Esteves Lima, 18.10.2007, v.u.). No mesmo sentido: STJ, HC 84.269-MS, 5ª Turma, rel. Napoleão Nunes Maia Filho, 11.12.2007, v.u.).

Assim, em primeira fase, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas (natureza da droga), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Torno a pena definitiva, à mingua de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição da pena.

Saliento que o caso concreto não se ajusta à figura do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33 § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois restou demonstrado que o réu se dedicava à atividade criminosa. Com efeito, os policiais militares que efetuaram a prisão do réu narraram que havia informações de que o réu traficava, o que é robustecido pela apreensão não apenas de entorpecente, mas de apetrechos para a mistura e embalagem das drogas (colheres, cartões, embalagens do tipo ziplock e lata, todos com resquícios de cocaína, conforme apontou o laudo pericial de fls. 162/167), além contabilidade do tráfico (fls. 23/23), demonstrado o tráfico reiterado de drogas e evidenciando seu profundo envolvimento com a criminalidade. Tais elementos concretos demonstram que não se trata de uma traficante de primeira viagem (o que ensejaria a aplicação do redutor), e permite concluir que fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida, estando inserida no espúrio comércio há algum tempo.

Pontuo que a natureza da droga já foi utilizada na fixação da pena-base, motivo pelo qual, em atenção ao tema 712 do STF, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006